

TRIBUNAL PLENO DE 23/10/2024

ITEM Nº 3

Processo: TC-014407.989.24-3

Representante: S & T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda.

Representada: Prefeitura de São Carlos

Responsável: Airton Garcia Ferreira (Prefeito)

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 59/2024, visando à formação de “*aquisição de produtos de uso pessoal a fim de atender a Prefeitura Municipal, pelo sistema de registro de preços*”.

Valor estimado: R\$ 8.319.177,00

Advogada: Fernanda Massad de Aguiar Fabretti (OAB/SP nº 261.232).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE DADOS RELATIVOS AO OBJETO. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO EXCESSIVA DE ITEM LICITADO. RECOMENDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Em exame representação formulada por **S & T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda.** face o edital do **Pregão Eletrônico nº 59/2024**¹, do tipo menor preço por lote², deflagrado pela **Prefeitura de São Carlos**, visando à “**aquisição de produtos de uso pessoal a fim de atender a Prefeitura Municipal, pelo sistema de registro de preços**”, com sessão pública originariamente designada para 4 de julho último.

¹ Processo administrativo nº 7.699/2024.

² Objeto dividido em 4 (quatro) lotes.

A sociedade empresária pleiteou a concessão de medida liminar de suspensão do certame e, no mérito, o reconhecimento da procedência da representação, com subsequente determinação de retificação dos vícios abaixo assinalados no instrumento convocatório:

- falta de dados relacionados ao teor informativo da “cartilha educativa” que deve ser fornecida junto aos kits de higiene íntima e bucal licitados³ (vale dizer, “se o próprio Município irá disponibilizar o teor da cartilha informativa” ou se incumbirá à contratada elaborá-la, e, neste caso, quais seriam os critérios e especificações técnicas correlacionadas);

- ausência de informações atinentes à palestra de conscientização que deverá ser ministrada pela futura contratada⁴, em termos quantitativos e de frequência;

- ausência de exigência de autorização de funcionamento de empresa e de licença de funcionamento, como critério de habilitação, documentos, segundo entende, indispensáveis à comprovação de regularidade sanitária, emitidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em favor de sociedades empresárias do ramo, nos moldes da Lei Federal nº 9.782/1999;

- indevida permissão de “participação de empresas varejistas”, na medida em que as descrições do objeto e as condições de participação não se

³ Extrato do Termo de Referência do edital (Anexo IV):

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os requisitos necessários para a presente contratação são: [...]

- O kit de higiene íntima deve conter uma cartilha educativa, 24 pacotes de absorvente higiênico feminino com 8 unidades cada, 12 embalagens de toalha umedecida com 16 unidades cada e um estojo multiuso, que deverão ser entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas e deverão, comprovadamente, estar em fase normal de produção/fabricação, não sendo aceitos materiais descontinuados ou fora de linha de produção do fabricante.

- O kit de higiene bucal deve conter uma cartilha educativa, 4 cremes dentais de 90 g, 4 escovas dentais, 4 fios dentais, 4 toalhas de rosto e um estojo multiuso, que deverão ser entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas e deverão, comprovadamente, estar em fase normal de produção/fabricação, não sendo aceitos materiais descontinuados ou fora de linha de produção do fabricante.

⁴ Extrato do Termo de Referência do edital (Anexo IV):

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os requisitos necessários para a presente contratação são: [...]

- A contratada deverá oferecer uma palestra com um orientador(a) sobre a importância da higiene bucal. O intuito dessa

palestra deverá ter como objetivo principal a orientação da saúde bucal.

- A contratada deverá oferecer uma palestra com um orientador(a) para impulsionar a conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso aos protetores menstruais higiênicos, que será fornecido pela Prefeitura municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Educação. O intuito dessa palestra tem como objetivo de informar e explicar a aceitação do ciclo menstrual como um processo natural do corpo e o reconhecimento como um sinal de saúde.

coadunariam com a respectiva modalidade comercial, situação que se confirmaria com a proibição de subcontratação de parcela do objeto⁵;

- excessivas especificações do estojo multiuso a ser fornecido em “kit de higiene íntima com cartilha educativa”⁶, o que direcionaria a contratação do item a uma única marca (“ECOPLASTBRASIL”);

- “ausência de razoabilidade e motivação” quanto à descrição do “kit de higiene bucal com cartilha educativa”, especificamente quanto às 4 (quatro) toalhas de rosto que comporão o conjunto⁷. De acordo com a autora, não há no mercado “qualquer marca que ofereça o produto dentro das condições excessivamente restritivas”, circunstância que poderia desencadear licitação deserta ou fracassada.

Na opinião da representante, os alegados defeitos do caderno de convocação, além de prejudiciais à correta e adequada formulação de propostas comerciais, encerram potencial de frustrar ou inibir a ampla competição do processo licitatório, sendo medida de rigor a correção dos pontos controvertidos.

Decisão preliminar de 2 de julho de 2024⁸ – **referendada** por este E. Plenário, em sessão ordinária de 3 de julho de 2024 – deferiu pleito de suspensão cautelar da licitação, notificando-se o responsável pelo Órgão

⁵ Extrato do Termo de Referência do edital (Anexo IV):

4.1. SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

⁶ Extrato do Termo de Referência do edital (Anexo I):

I.1. KIT DE HIGIENE ÍNTIMA COM CARTILHA EDUCATIVA

O Kit será composto por: [...]

01 (um) Estojo multiuso, rígido e resistente, confeccionado em PP biodegradável (polipropileno) cor a ser escolhida, medidas mínimas: 210 mm (comprimento) x 90 mm (largura) x 50 mm (altura), fechamento com trava frontal e dobradiça no próprio corpo. Necessária furação apropriada para arejamento interno, quando fechado. Personalização em quadricromia conforme arte a ser fornecida. Obrigatória apresentação de laudo laboratorial comprovando atendimento da Norma ABNT NBR 16.040:2020 (Isenção de ftalatos) e laudo laboratorial atestando níveis aceitáveis de Bisfenol (BPA free) e comprovação do uso de aditivo biodegradável, em conformidade com o padrão de testes ASTM 6954-04, NORMA BS 8472. Deverá constar impressa a frase “ESTE PRODUTO É RECICLÁVEL OU BIODEGRADÁVEL, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VENDA PROIBIDA”.

⁷ Extrato do Termo de Referência do edital (Anexo I):

I.2. KIT DE HIGIENE BUCAL COM CARTILHA EDUCATIVA

O kit será composto por: [...]

04 (quatro) toalha de rosto de tecido felpudo 100% algodão. Apresentar Laudo laboratorial, acreditado pelo INMETRO, conforme a norma ABNT NBR 12.853/1993 (tecidos felpudos e aveludados/determinação da hidrofiliidade).

⁸ Publicada no D.O.E. de 04 de julho de 2024.

Licitante a apresentar razões de defesa e documentação de interesse. Nada obstante, este se **manteve silente**.

Assessoria Técnico-Jurídica⁹ - ATJ (acompanhada por sua Chefia¹⁰) deduz a procedência das críticas alusivas à insuficiência de dados relacionados ao teor informativo da “cartilha educativa” e à ausência de informações atinentes à palestra de conscientização, bem como a parcial procedência do questionamento referente à excessiva especificação dos estojos multiusos.

No que tange à autorização de funcionamento e à licença de funcionamento, conclui pela improcedência da crítica, pois, consoante entende, “o edital é claro ao informar, em seu item 8.1, que ‘os documentos previstos no Termo de Referência, **necessários e suficientes** para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021’”. E diante de tal panorama, por se tratar de “**documentação indispensável à constituição regular da empresa e ao lícito exercício de sua atividade econômica**”, seria “conveniente, porém não obrigatório, que o texto convocatório especifique nominal e individualmente todos os documentos do gênero, estando [, no entanto,] a municipalidade de São Carlos compelida a requerer dos licitantes, desde logo (nos termos do item 8.1 do edital e do art. 66 da Lei), toda e qualquer autorização ou licença compulsória e inerente às atividades por eles desenvolvidas e expedidas pelos mais diversos órgãos públicos, independente de específica e minuciosa previsão no edital, dentre as quais as descritas na RDC nº 16/2014 expedida pela ANVISA, recém alterada pela RDC nº 860, de 06/05/2024”.

Manifesta-se, ademais, pela improcedência das críticas relacionadas às especificações acerca do item “toalhas de rosto” e “à possibilidade de participação do ramo varejista no torneio” (porquanto “ainda que o formato de execução do objeto, de fato, não favoreça ou estimule a adesão de empresas do varejo, a jurisprudência da Corte vem admitindo a

⁹ Evento 40.

¹⁰ Evento 40.1.

participação de empresas deste particular segmento do comércio em certames da espécie”).

Em preliminar, o **d. Ministério Público de Contas¹¹ - MPC** pugna a aplicação de multa ao responsável pelo torneio, por descumprimento de determinação exarada na decisão preliminar quanto à apresentação de cópia do edital e demais informações ali requisitadas.

Quanto ao mérito, manifesta-se igualmente pela **procedência parcial** da matéria, concluindo como legítimas as mesmas insurgências consideradas válidas por **ATJ**.

Pondera, outrossim, em linha com a d. ATJ, que a disposição do artigo 66 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que, na hipótese de a atividade envolvida no objeto licitado exigir autorização de funcionamento, como no caso em apreço, a imposição de apresentação de tal documento é **compulsória** à habilitação jurídica. Nada obstante, conclui que “em atenção aos princípios do julgamento objetivo e vinculação ao edital, só poderá ser cobrado se previsto expressamente no instrumento convocatório. Assim, a fim de dirimir qualquer dúvida sobre os documentos a serem apresentados para fins de habilitação jurídica, necessário que a Prefeitura retifique o edital, incluindo expressamente a exigência de apresentação da autorização para o exercício da atividade”.

GCMAB / LMN

¹¹ Evento 45.

TC-014407.989.24

VOTO

MÉRITO

Prosperam em parte as controvérsias suscitadas por **S & T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda.** em face do edital do Pregão Eletrônico nº 59/2024, instaurado pela Prefeitura de São Carlos, com vistas à “aquisição de produtos de uso pessoal a fim de atender a Prefeitura Municipal, pelo sistema de registro de preços”.

Primeiramente, improcedem as críticas direcionadas à possibilidade de participação de empresas varejistas na disputa e às especificações do item licitado “toalha de rosto”.

Com efeito, embora o formato da execução do objeto não fomente o interesse de sociedades empresárias varejistas, a jurisprudência desta Corte é favorável à participação de empresas desse segmento em certames da espécie, por questão de tratamento isonômico entre potenciais proponentes. Nesse sentido, decisões proferidas nos autos das Representações TC-011367.989.22¹² e TC-011742.989.23¹³.

Ademais, a pretensão da representante em impedir a participação de empresas varejistas trilha na contramão do princípio da ampla competitividade, que deve nortear os processos licitatórios.

De igual sorte, em linha com ATJ e MPC, não vislumbro irregularidade nas especificações da “toalha de rosto” a ser fornecida

¹² Decisão do Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, de 15 de junho de 2022 (publicada no D.O.E. de 21 de junho de 2022, transitada em julgado em 12 de junho de 2022), de relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

¹³ Decisão do Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, de 21 de junho de 2023 (publicada no D.O.E. de 14 de julho de 2023, transitada em julgado em 4 de agosto de 2023), de relatoria do e. Conselheiro Renato Martins Costa.

juntamente com o Kit de higiene bucal¹⁴, porquanto encerra características de natureza comum, relacionadas à satisfatória absorção de água e cuidado com a pele do usuário, aspectos elementares do produto almejado.

Por outro lado, à luz dos elementos técnicos que instruem os autos, do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, do disposto no artigo 66 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, conforme registrado pelo d. MPC, de forma a evitar qualquer dubiedade quanto aos documentos exigidos, necessária a inclusão, no edital, de cláusula expressa acerca da documentação indispensável à comprovação da idoneidade jurídica e do regular funcionamento de sociedades empresárias do ramo, na forma dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.360/76¹⁵, consoante jurisprudência desta Corte.

Nessa vereda, entendimento deste E. Tribunal Pleno, firmado nos autos da Representação TC-023180.989.20-4¹⁶⁻¹⁷, o qual invoco como razão de decidir dos presentes, em seus termos e fundamentos:

¹⁴ Extrato do Termo de Referência do edital (Anexo I):

I.2. KIT DE HIGIENE BUCAL COM CARTILHA EDUCATIVA

O kit será composto por: [...]

04 (quatro) toalha de rosto de tecido felpudo 100% algodão. Apresentar Laudo laboratorial, acreditado pelo INMETRO, conforme a norma ABNT NBR 12.853/1993 (tecidos felpudos e aveludados/determinação da hidrofiliidade).

¹⁵ Excerto da Lei Federal nº 6.370/76:

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.

¹⁶ Decisão do E. Tribunal Pleno desta Corte, de 25 de novembro de 2020 (publicada no D.O.E. de 17 de fevereiro de 2021, transitada em julgado em 10 de março de 2021), de relatoria do e. Conselheiro Renato Martins Costa.

¹⁷ No mesmo sentido, restou consignado:

- no **TC-011742.989.23, Pleno, sessão de 21/6/2023, Rel. e. Conselheiro Renato Martins Costa**: "Determinada a separação do objeto, vale consignar, a propósito dos itens classificados como de higiene pessoal, a abordagem consagrada em nossa jurisprudência que, analisando o assunto à luz da Resolução RDC/ANVISA nº 16/2014 e da Portaria CVS nº 01/2018, da Secretaria de Estado da Saúde, salvaguarda eventual licitante que, por força de lei local, não esteja subordinada às licenças de funcionamento expedidas pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual ou Municipal, ressaltando-a, portanto, de comprovações dessa natureza na fase de habilitação. Nesse sentido, não obstante cabível a exigência de Autorização de Funcionamento (AFE) de qualquer licitante que venha a contratar com a Administração, uma vez que equiparada, pela norma, à condição de atacadista/distribuidora, deve o futuro Edital consignar ressalva expressa quanto à dispensa da Licença de Funcionamento das empresas varejistas e/ou demais empresas que não se encontram sujeitas à exigência pela legislação local. Ademais, ainda que configurem documentos estritamente relacionados à fase de habilitação, igualmente demandariam reposicionamento em um futuro instrumento porque, se de requisitos de qualificação técnica não se tratam, só podem ser especificamente exigidos como elemento comprobatório de habilitação jurídica".

- no **TC-11367.989.22, Pleno, sessão de 15/6/2022, Rel. e. Conselheiro Sidney Beraldo**: "Mesma sorte, contudo, não emprego à dispensa de apresentação da AFE pelas empresas varejistas (item 1.14.1), pois 'a exigência não se limita aos fabricantes e importadores, devendo alcançar, de forma isonômica, os eventuais licitantes distribuidores e até mesmo os varejistas, equiparados ao comércio atacadista para os efeitos da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 16/2014, a compreender 'o comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos,

“Consoante aponta a instrução, o objeto licitado abrange a aquisição de produto sujeito às normas sanitárias, pressupondo, no aspecto da habilitação jurídica, a apresentação da Autorização de Funcionamento expedida pela Anvisa (AFE), assim como da Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária local, por se tratar de documentos determinantes para o exercício da atividade empresarial no ramo do fornecimento pretendido, conforme teor dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.360/76.

O entendimento jurisprudencial até aqui construído caminha no sentido de estender a necessidade de apresentação da Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE expedida pela ANVISA também às empresas dedicadas ao comércio varejista, desde que, por força de relação jurídica obrigacional travada com outra pessoa jurídica, seja equiparada às atacadistas.

Distingue-se a situação, portanto, daquelas em que a comercialização ou distribuição de produtos domissanitários ocorre em quantidades compatíveis com o consumo próprio e direto da pessoa física, contexto no mais das vezes refletido no mercado de varejo e que, assim, dispensa a aludida autorização.

Não sendo essa a hipótese dos autos, como de fato não é o negócio celebrado com a Administração porquanto pessoa jurídica de direito público, de rigor que o Edital demande a aludida comprovação documental de todas as licitantes.

Tal entendimento, todavia, não se estende à Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária, regida por regramento estadual ou municipal específico que, conforme o caso, pode estabelecer critério de diferenciação em razão da atuação da empresa e/ou do produto comercializado.

Deve o Edital, com isso, excepcionar de tal exigência as empresas varejistas e as demais que não se encontram sujeitas a tal demanda pela legislação local.”

Quanto ao mais, é incontroversa a falta de dados atinentes ao conteúdo informativo da “cartilha educativa” e à ausência de informações sobre

as palestras de conscientização em relação aos produtos almejados, lacunas que devem ser saneadas em eventual reedição do caderno de convocação.

O edital limita-se unicamente a determinar, de maneira genérica, que a cartilha educativa descreva “a importância da conscientização sobre a menstruação e a higiene bucal”, bem como a estabelecer (Anexo I) especificações estéticas (“dimensões do documento, número mínimo e coloração de páginas, gramatura da folha e tipo de impressão”), ressentindo-se, todavia, de qualquer orientação clara e precisa do teor informativo do material, a qual deve constar do caderno de convocação, porquanto essencial à adequada elaboração de propostas e efetiva consecução do ulterior contrato, uma vez que o material integra o objeto em disputa.

De igual modo, cabe ao instrumento convocatório indicar os dados atinentes à almejada palestra de conscientização da importância da higiene bucal e da universalização do acesso aos protetores menstruais, em termos quantitativos, de frequência e a forma de sua realização (se presencial ou remota), aspectos fundamentais ao dimensionamento dos custos, porém, não vislumbrados.

Por outro lado, procede parcialmente a reclamação voltada à excessiva especificação dos estojos multiuso a serem fornecidos em “kit de higiene íntima” ¹⁸.

Segundo parecer da ATJ, endossado pelo MPC, além da limitação à material específico de confecção (PP biodegradável - polipropileno), são excessivas e restritivas as dimensões requeridas para o item, em contrariedade à jurisprudência da Corte e à legislação disciplinadora.

¹⁸ Extrato do Termo de Referência do edital (Anexo I):
I.1. KIT DE HIGIENE ÍNTIMA COM CARTILHA EDUCATIVA
O Kit será composto por: [...]

01 (um) Estojo multiuso, rígido e resistente, confeccionado em PP biodegradável (polipropileno) cor a ser escolhida, medidas mínimas: 210 mm (comprimento) x 90 mm (largura) x 50 mm (altura), fechamento com trava frontal e dobradiça no próprio corpo. Necessária furação apropriada para arejamento interno, quando fechado. Personalização em quadricromia conforme arte a ser fornecida. Obrigatória apresentação de laudo laboratorial comprovando atendimento da Norma ABNT NBR 16.040:2020 (Isenção de ftalatos) e laudo laboratorial atestando níveis aceitáveis de Bisfenol (BPA free) e comprovação do uso de aditivo biodegradável, em conformidade com o padrão de testes ASTM 6954-04, NORMA BS 8472. Deverá constar impressa a frase “ESTE PRODUTO É RECICLÁVEL OU BIODEGRADÁVEL, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VENDA PROIBIDA”.

No entanto, não há desconformidade na “requisição de produtos isentos de ftalatos, com níveis aceitáveis de Bisfenol (BPA free) e que utilizem aditivo biodegradável, imposições de segurança e sustentabilidade restritas ao estojo multiuso, produto que não dispõe de certificação compulsória pelo INMETRO, de modo que a cautela da Administração, neste particular cenário, mostra-se não apenas razoável como salutar, com vistas à preservação da saúde dos alunos e do meio ambiente”.

A despeito disso, “mostra-se necessário avaliar se a comprovação das características de qualidade indicadas no texto (hidrofilidade, BPA free e ausência de ftalatos) não poderia ser feita, igualmente, por eventuais certificações, declarações, certificados de qualidade, além dos habituais laudos técnicos [conforme prevê o artigo 42, III, da Lei 14.133/2021¹⁹], ampliando assim as possibilidades de qualificação de licitantes ao torneio”, providência que **recomendo** ao Órgão Licitante.

Sem prejuízo da recomendação citada e circunscrito às particulares condições editalícias inquiridas, voto pela **procedência parcial** da representação por S & T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda., **determinando-se** à Prefeitura de São Carlos, caso pretenda retomar o Pregão Eletrônico nº 59/2024, a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- insira cláusula expressa, acerca dos requisitos de habilitação jurídica, quanto à documentação indispensável à comprovação da idoneidade jurídica e do regular funcionamento de sociedades empresárias do ramo, dispensando-se, contudo, a obrigação de apresentação de licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária para as empresas que não se encontram sujeitas a tal demanda, por força de legislação local, consoante anteriormente explicitado;

¹⁹ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios: [...]
III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

- indique, de maneira clara e precisa, o teor do conteúdo informativo que deve compor as “cartilhas educativas” licitadas, bem como os dados atinentes à almejada palestra de conscientização da importância da higiene bucal e da universalização do acesso aos protetores menstruais, em termos quantitativos, de frequência e a forma de sua realização (se presencial ou remota).

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão Licitante atentar para a necessária republicação do edital, consoante lei de regência.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB / LMN/rjc